

1530635-65.2022.8.26.0050

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: FABRICIO REALI ZIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... e dependentes e, por fim, reprimir a produção e tráfico ilícito de drogas.

Assim, percebe-se que a lei pretende diminuir a quantidade de drogas que circula no país, pois pretende coibir o tráfico, prevenir o uso e cuidar do dependente, com medidas de reinserção social. Percebe-se, outrossim, que a lei aproxima a questão do uso e da dependência como questão de saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

Vara do Juizado Especial Criminal

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, 1º ANDAR RUA 7 - SALAS 518/586, BARRA FUNDA - CEP

01133-020, Fone: 11 2868-7251, São Paulo-SP - E-mail: spjecrim@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1530635-65.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FRANCISCO SOARES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ FERNANDO STEINBERG

Vistos.

Primeiro, no que tange à prática do delito previsto no artigo 50 da Lei 3.688/41. Consta dos autos ter sido o autor encontrado explorando jogo de azar em lugar acessível ao público.

É o caso de se conceder, de ofício, ordem de habeas corpus para o trancamento de referido termo circunstanciado.

De início, observo que, na esteira da jurisprudência pátria, ser possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício quando constatada a ilegalidade flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal (STJ - Rel. Og. Fernandes. T6 - SEXTA TURMA DJe 31/05/2013 - 31/5/2013 - HC 264306 SP 2013/0028420-1).

O art. 648, I, do CPP, por outro lado, dispõe que a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa.

Na expressão "justa causa", a seu turno, devem ser entendidas questões atinentes ao suporte probatório mínimo para a existência da lide penal ou mesmo questões

referentes ao mérito da conduta a ser apurada.

No caso sob exame, a questão é atinente ao mérito, mais especificamente à inexpressividade da lesão jurídica causada pela mínima ofensividade da conduta do agente, a qual se constatou despicienda pela quantidade ínfima de máquinas e de acessórios caça-níqueis apreendidos, conforme se observa no auto de fls. 3/4, configurando assim, de forma inequívoca, a atipicidade material da conduta.

Outrossim, há de se invocar os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade penal, em que o Direito Penal somente deva ser utilizado para a resolução de conflitos, quando outras esferas do Direito, menos coativas, mostrarem-se insuficientes para tanto.

Nesse sentir, revelar-se-ia, no caso concreto, legítima a possibilidade de o Estado coibir tal atividade sem atingir a esfera penal, no próprio plano administrativo, como já ocorre em algumas unidades federativas e municipalidades, mantendo-se, portanto, íntegros os referidos princípios.

Além disso, a própria recepção do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 pela Constituição Federal de 1988, o qual tipifica a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais, encontra-se em discussão no STF, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 924) no STF, tendo como leading case justamente o v. acórdão em que esta decisão foi embasada, o RE 966.177/RS. Nesse sentido:

Recurso Extraordinário. Contravenção Penal. Artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941. Jogo de azar. Recepção pela Constituição Federal. Tipicidade da conduta afastada pelo tribunal a quo fundado nos preceitos constitucionais da livre iniciativa e das liberdades fundamentais. Artigos 1º, iv, 5º, XLI, e 170 da Constituição Federal. Questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Transcendência de interesses. Existência de repercussão geral.

Manifestação: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue abaixo:

Apelação crime. Jogos de azar. Art. 50 do DL 3.688/41. Atipicidade. Conduta inserida no âmbito das liberdades individuais, enquanto direito constitucional intocável. Os fundamentos da proibição que embasaram o Decreto-Lei 9.215/46 não se coadunam com a principiologia constitucional vigente, que autoriza o controle da constitucionalidade em seus três aspectos: evidência, justificabilidade e intensidade. Ofensa, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da lesividade, que veda tanto a proteção insuficiente como a criminalização sem ofensividade. Por outro lado, é legítima a opção estatal, no plano administrativo, de não tornar legal a atividade, sem que tal opção alcance a esfera penal. Recurso Provido.

Dessa forma, entendendo este magistrado pela atipicidade material da conduta do agente, diante das poucas máquinas e acessórios apreendidos, bem como em respeito ao princípio da intervenção mínima e da subsidiariedade penal, pois possível o controle da conduta no plano administrativo, anoto ser de rigor a concessão da ordem e o trancamento deste procedimento investigativo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 648, I, do CPP, CONCEDO, de ofício, a ORDEM DE HABEAS CORPUS e determino o TRANCAMENTO do presente TERMO CIRCUNSTANCIADO.

Deixo de submeter a decisão ao duplo grau obrigatório, consoante art. 574, I, do CPP, pois tenho que, salvo opiniões em sentido contrário, numa visão garantista, tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988, eis que esta garante ao Ministério Público, nos termos do seu art. 129, I, a titularidade da ação penal pública, o que era diverso quando do advento do Código de Processo Penal que previa as hipóteses de ação penal iniciada pelo próprio juiz - por isso do

“recurso” pelo próprio Magistrado.

Portanto, dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para a destruição dos objetos ilícitos apreendidos às fls. 3/4.

Quanto à quantia em espécie apreendida, após o trânsito, diante de sua origem ilícita, decreto, desde já, o perdimento em favor da FUNPESP. Oficie-se.

Em relação à prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Consta dos autos ter sido o autor encontrado com droga para o consumo pessoal.

É o caso de se conceder, de ofício, ordem de habeas corpus para o trancamento de referido termo circunstanciado.

De início, observo que, na esteira da jurisprudência pátria, é possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício quando for constatada a existência de ilegalidade flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal (STJ – Rel. Og. Fernandes. T6 - SEXTA TURMA DJe 31/05/2013 - 31/5/2013 - HC 264306 SP 2013/0028420-1).

O art. 648, inc. I, do CPP, por outro lado, dispõe que a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa.

Na expressão “justa causa”, a seu turno, devem ser entendidas questões atinentes ao suporte probatório mínimo para a existência da lide penal ou mesmo questões referentes ao mérito da conduta a ser apurada.

No caso dos autos a questão é atinente ao mérito, mais especificamente a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, em face da quantidade ínfima de entorpecente apreendido, configurando assim atipicidade da conduta.

Este Magistrado, reiteradamente, vem rejeitando denúncias e arquivando feitos, a requerimento do Ministério Público, ao argumento da atipicidade no tocante ao artigo 28 da Lei 11.343/06 (Vide HC 110475/SC – SANTA CATARINA – Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma).

O princípio da insignificância teve origem na máxima romana do *minima non curat praetor*, vale dizer, o pretor não se ocupava de causas ínfimas, desprezíveis ou um nada jurídico.

Contudo, a versão contemporânea, hoje observada pela doutrina e pela jurisprudência, foi idealizada por Claus Roxin quando o autor alemão estudou a influência da política criminal no sistema penal até então preconizado pela dogmática. Em outras palavras, a influência de questões político-criminais nos elementos constitutivos do conceito de crime.

O princípio da insignificância deve ser entendido como verdadeiro princípio geral de direito penal, que auxilia na interpretação do injusto penal: traduz-se na conduta ou ataque ao bem jurídico tutelado pela norma penal de ínfima ou nenhuma relevância social. Tal ação (e porque não omissão) não requer a (ou mesmo não necessita da) imposição de pena criminal.

Assim, o princípio da insignificância – na visão absoluta como visto atualmente pela doutrina e jurisprudência, vetor de interpretação restritiva do tipo penal e excludente supralegal de tipicidade, atua quando a ofensa do bem protegido for considerada ínfima (desprezível).

A insignificância, que pode ser caracterizada do ponto de vista absoluto

(excludente de tipicidade), consiste naquelas condutas que são desprezíveis, um nada jurídico que não ofende nem coloca em risco o bem tutelado pela lei penal.

Em linhas gerais, o princípio da insignificância transforma a conduta que era típica, sob a ótica formal, em atípica, do ponto de vista material, na medida em que a ofensa ao bem jurídico é tão ínfima (desprezível) que não se justifica a intervenção do direito penal com todos os seus mecanismos de repressão.

É exatamente o caso dos autos, uma vez que a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo entorpecente para o consumo próprio, ainda mais considerada a pequena quantidade, deve ser considerada materialmente atípica.

Com efeito, ainda que questionável a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, tanto que o Supremo Tribunal Federal admitiu a repercussão geral nesta questão, diante do disposto no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, é fato que o art. 28, não obstante em menor escala se comparável com as outras condutas prevista na Lei, tem como bem jurídico tutelado a saúde pública.

E não poderia ser de outro modo eis que, caso não existisse bem jurídico a ser protegido pela Lei Penal, desnecessária seria a intervenção da própria lei penal – ultima ratio, restando a conduta acolhida, protegida ou tutelada pelos demais ramos da ciência jurídica, consoante os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade.

O art. 1º da Lei 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, esclarece quais as finalidades do diploma legal, que são: prevenir o uso indevido de drogas; promover a reinserção social de usuários e dependentes e, por fim, reprimir a produção e tráfico ilícito de drogas.

Assim, percebe-se que a lei pretende diminuir a quantidade de drogas que circula no país, pois pretende coibir o tráfico, prevenir o uso e cuidar do dependente, com medidas de reinserção social. Percebe-se, outrossim, que a lei aproxima a questão do uso e da dependência como questão de saúde pública e este é o interesse jurídico que a lei visa tutelar.

Portanto, em que pese o art. 28 não conter em seu preceito secundário pena privativa de liberdade, é fato que o legislador, talvez por falta de coragem, ainda considere a conduta como crime, não obstante com um viés de inconstitucionalidade e, como tal, o bem tutelado é a saúde pública, tanto sob o prisma individual, daquele que consome a droga, como daquele que distribui o entorpecente (coletivo). Considera, assim, o legislador, o bem jurídico desde o plantio, fabrico e distribuição da droga até o consumidor final, não obstante deva este receber tratamento, eis que busca a lei evitar a estigmatização (art. 19, II), ao invés de ser considerado “criminoso”.

Pois bem. Em que pese ser o bem tutelado a saúde pública, como visto, ainda que em menor escala, já que equipara o consumidor de droga ao dependente, nada impede que se reconheça a insignificância absoluta, excluindo a tipicidade material da conduta, como vem fazendo rotineiramente o Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte brasileira, ao analisar o postulado da insignificância, orienta-se pelos critérios fixados pelo Min. Celso de Mello no Habeas Corpus n. 84.412-0/SP, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Frise-se que, em relação aos critérios desenvolvidos pelo STF, dois deles (mínima ofensividade da conduta do agente e nenhuma periculosidade social da ação) referem-se ao desvalor da conduta; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento à

culpabilidade e o último, inexpressividade da lesão jurídica provocada, ao desvalor do resultado.

Em relação ao delito do art. 28 (e entende-se que é crime) nem todos os pressupostos necessariamente devem estar presentes.

Deve-se analisar o requisito (ou pressuposto) da inexpressividade da lesão jurídica provocada, eis que se trata de crime de perigo abstrato (ou presumido), do qual, como se verá, o resultado natural vem afastado do tipo penal. Todavia, necessária a perquirição acerca da lesividade da conduta.

Em casos como o presente, é de se considerar a mínima ofensividade da conduta do agente tendo em conta a pequena quantidade de droga apreendida já que, do contrário, a conduta típica em tese seria outra e mais grave; e o requisito da nenhuma periculosidade social da ação na medida em que, como prega a própria lei, o consumidor de droga deve ser tratado como usuário ou mesmo dependente e, para tanto, serem tomadas todas as medidas necessárias para sua reinserção social, evitando a estigmatização.

Em outras palavras: a conduta não possui ofensividade suficiente ao reconhecimento da tipicidade material, já que é ínfima a quantidade de droga e, ainda, por ser o agente em tese dependente, afigura-se necessária sua reinserção social e não sua estigmatização, aliás, como é o desiderato da lei, o que afasta qualquer periculosidade social.

Por fim, não se analisará o grau de reprovabilidade do comportamento, eis que se trata de elemento afeto à culpabilidade, visto como (des) necessidade de pena e que deve levar em consideração critérios de ordem pessoal (primariedade e antecedentes) para o reconhecimento, o que somente é analisado quando se trata de insignificância relativa, quando, de fato, há violação ao bem tutelado e passa-se para fase da aplicação da pena, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, julgado da E. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida. (STF - HC 110.475-SC - Rel. Min. Dias Toffoli - 1ª T - 14.02.2012).

Anote-se que, em reforço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do postulado da insignificância absoluta como vetor de interpretação restritiva do tipo penal e excludente de tipicidade material, quando o delito ocorre em local sujeito à administração castrense, em que há a rigorosa observância dos princípios da hierarquia e disciplina, consoante art. 142 da CF/88.

Ora, se a Suprema Corte admite o reconhecimento do postulado da insignificância em local que necessária a hierarquia e disciplina, com maior razão este princípio deve ser reconhecido nas demais situações.

Nesse sentido:

E M E N T A: CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) - PORTE (OU POSSE) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - QUANTIDADE ÍNFIMA - USO PRÓPRIO - DELITO PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - APLICABILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - PEDIDO DEFERIDO. - Aplica-se, ao delito castrense de porte (ou posse) de substância entorpecente, desde que em quantidade ínfima e destinada a uso próprio, ainda que cometido no interior de Organização Militar, o princípio da insignificância, que se qualifica como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal. Precedentes. (STF - HC n. 97.131RS - Rel. Min. Celso de Mello - 2ª T - 10.08.2010).

EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Posse e uso de substância entorpecente. Art. 290, cc. art. 59, ambos do CPM. Maconha. Posse de pequena quantidade (8,24 gramas). Princípio da insignificância. Aplicação aos delitos militares. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim, vencida a Min. ELLEN GRACIE, rel. originária. Precedentes (HC nº 92.961, 87.478, 90.125 e 94.678, Rel. Min. EROS GRAU). Não constitui crime militar a posse de ínfima quantidade de substância entorpecente por militar, a quem aproveita o princípio da insignificância. (STF - HC n. 94.583/MS - Rel p acórdão Min. Cezar Peluso - 2ª T - j 24.06.2008).

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. Não constitui crime militar trazer consigo quantidade ínfima de substância entorpecente (4,7 gramas de maconha), em atenção ao princípio da insignificância. Ordem concedida para absolver o paciente. (STF - HC n. 91.074-2 - SP - Rel. Min. Joaquim Barbosa - 2ª T - 19.08.2008).

CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) - POSSE (OU PORTE) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - QUANTIDADE ÍNFIMA - USO PRÓPRIO - DELITO PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - APLICABILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - PEDIDO DEFERIDO. - Aplica-se, ao delito castrense de posse (ou porte) de substância entorpecente, desde que em quantidade ínfima e destinada a uso próprio, ainda que cometido no interior de Organização Militar, o princípio da insignificância, que se qualifica como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal. Precedentes. (STF - HC 101759/MG - Rel. Min. Celso de Mello - 2ª T - 10.08.2010).

Portanto, presentes os pressupostos ou requisitos atinentes à conduta e ao resultado, imperioso é o reconhecimento da causa supralegal excludente da tipicidade material.

Por outro lado, ainda, não obstante a posição firmada pela Suprema Corte, que o fato de se tratar crime de perigo abstrato ou presumido (STF, HC 82.324-6, 1ª T, j. 15.10.2002, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 22.11.2002, RT 812/490) não é óbice ao reconhecimento da excludente supralegal de tipicidade.

Com efeito, segundo abalizada doutrina: "crime de perigo é aquele que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido, sem produzir um dano efetivo. (...) o perigo abstrato é presumido juris et de jure. Não precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a simples prática da ação que pressupõe perigosa" (BITENCOURT, Cesar Roberto e CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do

delito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 27). “O tipo de perigo abstrato é a técnica utilizada pelo legislador para atribuir a qualidade de crime a determinadas condutas, independentemente da produção de um resultado naturalístico. Trata-se de prescrição normativa cuja completude se restringe à conduta, ao comportamento descrito no tipo, sem nenhuma referência aos efeitos exteriores do ato, ao contrário do que ocorrer com os delitos de lesão ou de perigo concreto” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 20123, p. 87).

Diferentemente dos crimes de danos, os quais causam efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, nos crimes de perigo tem-se uma potencialidade de lesão, realizável ou não. Nos crimes de perigo abstrato, diferentemente dos de perigo concreto, dispensa-se a constatação de eventual perigo real (mensurável) ao bem jurídico, contentando-se o legislador com a prática da conduta e o perigo presumido de lesão.

Ora veja: em se tratando das condutas do art. 28, basta o porte da droga (e aqui englobando todas as condutas nucleares), independentemente de qualquer resultado, para o crime restar consumado. Todavia, a quantidade da droga deve ser tal que coloque em risco potencial o bem tutelado, qual seja, a saúde pública, o que não se observa do caso concreto.

Assim, o argumento de que, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, que tutela a saúde pública, seria irrelevante a quantidade de droga, não convence e não obstaculiza o reconhecimento da insignificância absoluta.

E mais: em se tratando de crime de perigo abstrato é imperiosa a verificação da lesividade da conduta para se aferir se o bem jurídico foi lesado ou realmente exposto a perigo de lesão.

Tratando do princípio da lesividade nos crimes de perigo abstrato, Pierpaolo Bottini assevera: “A lesividade dos crimes de perigo abstrato deve estar presente tanto no plano legal, por meio de dispositivos claros e taxativos que permitam o reconhecimento dos interesses que visa resguardar, quanto no plano fático, ou seja, o juiz, ao aplicar a norma, deverá perquirir pela lesividade da conduta diante das circunstâncias concretas que envolvem sua prática. Esta verificação do potencial lesivo do comportamento se faz por um juízo de periculosidade da ação descrita no tipo como de perigo abstrato. Apenas a conduta que ostente periculosidade tem o condão de movimentar o direito penal de forma legítima. As ações ou omissões que não impliquem riscos, ao menos potenciais, de afetação do bem jurídico, não podem interessar ao sistema repressor (id. Ibid. p. 156/167).

A lesividade nos crimes de perigo abstrato não pode ser simplesmente desprezada com simples argumento de que o bem jurídico é coletivo (saúde pública) sob pena de se concretizar uma intervenção jurídica inócua, ineficaz e desnecessária diante dos princípios da subsidiariedade e intervenção mínima, além da desproporcionalidade entre a írrita conduta e a sanção eventualmente aplicada, que pode trazer consequências penais (p. ex. reincidência), processuais (ex. obstar transação penal) ou de execução penal (indeferimento de benefícios).

Destarte, o desprezo à lesividade consistiria, em verdade, em ofensa aos instrumentos de proteção dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição que, no fim das contas, são corolário da dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo de toda ordem constitucional.

Ainda, de se afirmar que não há dúvida que o estado deva tutelar bens supraindividuais, como o é a saúde pública. Entretanto, esta tutela não pode levar a intervenção penal em situações que, materialmente, e concretamente, não a ofendem de forma direta nem a colocam em risco.

Assim, o simples argumento de se tratar de crime cujo bem jurídico é a saúde pública e, por tal motivo, inaplicável a insignificância, deve ser rechaçado.

Portanto, no caso em apreço, a toda evidência, a conduta de portar (incluindo todas as condutas típicas do art. 28) o agente a inexpressiva quantidade de droga para consumo próprio, embora seja formalmente típica, por absoluta capacidade de ofensa ao bem jurídico, qual seja, a saúde de terceiros e do próprio agente (incolumidade pública), é materialmente atípica por ser absolutamente insignificante.

Apenas frise-se, por derradeiro, que por se tratar de insignificância absoluta, qual seja, aquela que exclui de plano a tipicidade da conduta, não são considerados dados subjetivos do agente (primariedade ou antecedentes) na medida em que estes requisitos são atinentes à aplicação da pena e somente têm relevância quando do reconhecimento da insignificância relativa, que é aquela que, não obstante tratar-se de conduta típica, leva ao reconhecimento da desnecessidade de pena e, por conseguinte, à exclusão da culpabilidade lato sensu vista sob o prisma da responsabilidade penal.

Na insignificância relativa, apenas para constar, a conduta não nasce insignificante, pois há lesão ou perigo de lesão aos bens tutelados pela norma penal, mas, depois, por questões de política criminal e posteriores à ocorrência do delito, considerando as finalidades da pena e as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), tornam-se um indiferente penal (ou isentas de pena), o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, verifica-se que o art. 5º, inc. X, da CF/88 prevê a garantia constitucional do direito à vida privada e à intimidade, no qual o espaço na vida do cidadão não deve ser acometido por intervenções externas, nem mesmo a do Estado.

Ademais, o princípio da intervenção mínima determina que o Direito Penal deva ser aplicado apenas como ultima ratio.

Destarte, verifica-se que não houve lesão ao bem jurídico tutelado pelo porte de entorpecentes para consumo pessoal, uma vez que tal conduta não extrapolou o âmbito individual, não havendo, portanto, tipicidade material no referido delito.

Nota-se, assim, ante aos princípios da insignificância, intervenção mínima e da garantia constitucional à privacidade e à intimidade, deve-se considerar atípica a conduta praticada pelo autor no presente caso.

Pois bem. Nem se alegue que a simples existência do termo circunstanciado, por si só, não geraria constrangimento ilegal.

Ora veja, não concedida a medida de ofício, e requerendo o Ministério Público a designação de audiência preliminar, o autor dos fatos seria compelido a vir a juízo (se encontrado) e assumir uma obrigação – no mais das vezes pecuniária – para não se ver processar.

Caso não cumpra, ou não compareça, ou mesmo não aceite, seria ofertada denúncia para, na sequência, ser ela rejeitada pela fundamentação acima.

Assim, não se revela razoável a movimentação da máquina judiciária para uma solução que será inevitável, qual seja, a rejeição da inicial.

No mais, não se alegue, ainda, que a transação penal se revelaria mais benéfica ao autor dos fatos na medida em que, caso aceite e cumpra, se tiver direito – extinta a punibilidade – ficará ele impedido de utilizar-se de aludido benefício pelo período de 5 anos.

Portanto, por todos os ângulos em que se olhe a questão, o trancamento nesta fase é a medida mais adequada.

Observo, no mais, a existência de precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em abono ao entendimento aqui sustentado: HC 110475, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012 RB v. 24, n. 580, 2012, p. 53-58 e ainda o HC 97.131/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 10 de agosto de 2010.

E, no mesmo sentido, são os votos proferidos até o presente momento no julgamento do RE 635.659, que trata da inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, com fundamento no art. 648, inc. I do CPP, CONCEDO, de ofício, ORDEM DE HABEAS CORPUS e determino o TRANCAMENTO do presente TERMO CIRCUNSTANCIADO.

Deixo de submeter a decisão ao duplo grau obrigatório, consoante art. 574, inc. I do CPP, pois tenho que, salvo opiniões em sentido contrário, numa visão garantista, tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988, eis que esta garante ao Ministério Público, nos termos do seu art. 129, inc. I, a titularidade da ação penal pública, o que era diverso quando do advento do Código de Processo Penal que previa as hipóteses de ação penal iniciada pelo próprio juiz - por isso do "recurso" pelo próprio Magistrado.

Portanto, dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição do entorpecente apreendido.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA